

1501898-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... circunstâncias que conduzem à vinculação ao tráfico organizado. Provido o recurso ministerial para agravar a reprimenda, desprovido o defensivo, com base em farta e recentíssima jurisprudência do e. STJ. (...) Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas apreendidas (2,206 kg de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501898-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501898-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MACÊDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DANILO MACÊDO DOS SANTOS foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2022, por volta de 19:20 horas, na Rua Francisco Alves Bezerra, 265, Jaçanã, nesta comarca da Capital, trazia consigo e vendia 105 (cento e cinco) invólucros contendo 43,8g de cocaína; 340 (trezentos e quarenta) invólucros contendo 64g de cocaína, na forma de pedras de crack; 81 (oitenta e um) invólucros contendo 499g de tetrahydrocannabinol; 244 (duzentos e quarenta e quatro) invólucros contendo 70,1g de tetrahydrocannabinol, na forma de skunk, substâncias proibidas e descritas como droga nos termos do artigo 66 da Lei 11.343/06 e Portaria SVS/MS 344/98, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 20.

Laudo de Constatação a fls. 24/27.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 192/193.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A procedência do pedido se faz como medida de rigor.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20, Laudo de Constatação de fls. 24/27 e Laudo Pericial de fls. 192/193, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, cocaína e maconha.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado optou por permanecer em silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 16).

Em Juízo, negou a acusação.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Pretendeu se fiar na oitiva da testemunha de Defesa Sueli, pessoa que pretendeu afirmar ter visto a prisão do acionado, sozinho, com ele não sendo apreendido nada de irregular.

No entanto, tal testemunha se mostrou absolutamente mendaz, sem qualquer crédito, na medida em que, estranhamente, só viu a prisão do acionado quando, outra testemunha, comum das partes, Luis Paulo, bem afirmou ter sido preso juntamente com o acionado.

Logo, seus relatos não podem ser tidos como sérios.

Como, também, sem qualquer credibilidade as declarações da testemunha Luís Paulo Freitas de Almeida, usuário de drogas visivelmente comprometido com a verdade dos fatos, de todo mendaz, que se dispôs a vir em Juízo narrar, em nítido torpor por uso de entorpecente ou substância análoga, e, sem qualquer compromisso sério, ter sido apreendido injustamente, tal como o réu, em local de venda de drogas, não sabendo como foram apreendidas drogas na oportunidade, em frontal dissidência com aquilo que ele mesmo informou na fase policial (fls. 09), relato que não merece crédito algum.

Pondero, ainda, que as filmagens apresentadas pela Defesa, no link de fls. 182, não mostram ou revelam o exato momento da abordagem e apreensão das drogas, e, sim, quando muito, o momento em que o acionado já se encontra preso e rendido pelos policiais, estes que enfrentam a revolta da população, onde qualquer palavra de abono ao acionado é dita pelos populares, ou mesmo por quem filma a cena.

Triste investida!

Doutro lado, temos os relatos precisos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Jonas Fernandes Gomes e Danilo de Jesus Lopes declararam, em versões absolutamente harmônicas, inclusive alinhadas com aquilo que informaram na fase policial, que, na data em questão, realizavam patrulhamento tático pela Rua Itamonte, sendo que, na esquina com a Rua Francisco Alves Bezerra, depararam-se com dois indivíduos em atitudes suspeitas, os quais, ao perceberem a presença policial, evadiram-se do local. Em uma viela próxima, os indivíduos posteriormente identificados como DANILO e Luís correram. Durante a fuga, DANILO jogou uma sacola no chão e, após alguns metros, caiu e foi detido. Em sua cintura foi localizado um estojo contendo em seu interior 340 porções de crack e 105 porções de cocaína, além de R\$ 160,00 em notas diversas. Indagado, de imediato relatou que estava realizando o tráfico no local. Luís também foi abordado, sendo encontrada em sua posse a quantia de R\$ 22,00, relatando ser usuário de drogas e havia acabado de chegar no local para comprar entorpecentes de DANILO, quando os policiais chegaram. Na sacola dispensada por DANILO, na sequência recuperada, foram localizadas 81 porções maconha, 187 porções maconha K2 e mais 57 porções de skank. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Danilo, que foi conduzido à presença da autoridade policial, juntamente com Luís e as drogas e valores apreendidos.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo e vendia drogas, consistentes em 105 (cento e cinco) porções de cocaína; 340 (trezentos e quarenta)

pedras de crack; 81 (oitenta e um) invólucros contendo maconha; e 244 (duzentos e quarenta e quatro) porções de skunk, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 770 (setecentas e setenta) unidades, a variedade e os tipos de entorpecentes encontrados, altamente lesivos, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, as circunstâncias do flagrante, a apreensão de dinheiro em espécie com o acusado, a abordagem de um dos clientes do comércio espúrio, no momento em que a transação seria realizada, os depoimentos firmes dos policiais que os abordaram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável deque o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, em que pese dispensável, no caso em apreço foi possível, inclusive, a identificação de um cliente da mercancia espúria promovida pelo acusado, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico nas modalidades de vender e trazer consigo.

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram de todo desfavoráveis.

Inicialmente, foram localizadas 770 porções de drogas em poder do acusado, quantidade extremamente elevada, que certamente coloca em grande risco o bem jurídico tutelado, ou seja, a saúde pública. Além disso, chamo atenção para a natureza dos entorpecentes, altamente lesiva, dentre os quais destaco a cocaína e o crack.

Assim, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, de rigor seja a pena base do acusado fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Mas não só!

Com efeito, da certidão de fls. 88/89 extrai-se que o réu possui maus antecedentes, decorrente de condenação definitiva pela prática, igualmente, do crime de tráfico de drogas.

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, acima analisadas, estabeleço sua pena base em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa.

Em segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, II, alínea "j)", do Código Penal, tendo em conta a data dos fatos (22/01/2022) e a edição do Decreto nº 64.879, de 20.03.2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de modo que reconheço ter sido praticado o crime em reconhecido estado de calamidade pública, decorrente da notória pandemia do vírus COVID-19.

Assim, elevo suas reprimendas em 1/6, alcançando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 700 (setecentos) dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo previsto em lei, reprimendas estas que torno definitivas, na medida em que ausentes causas de aumento ou diminuição de penas.

Vale observar que, no caso, inviável a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06.

Com efeito, ausentes os requisitos legais, que são cumulativos, para tanto.

Eis a letra da lei: Art. 33. (...). § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ora, em que pese tecnicamente primário, é evidente que não se pode concluir que alguém participe de venda de elevado volume de entorpecentes, revelador de entregas particularizadas, não se dedique a atividades criminosas ou mesmo não tenha ligação com alguma organização criminosa.

Nesta toada, é importante recordar a ratio essendi do privilégio previsto na norma em comento, qual seja, beneficiar o denominado pequeno traficante, aquele que de maneira absolutamente primária e “amadora” acabou se deixando levar por caminhos escusos à prática da mercancia ilícita de pequeno vulto, fazendo com que não ingresse no sistema prisional e lá tenha contato com criminosos de maior envergadura, o que poderia, ao invés de afastá-lo do crime, introduzi-lo ainda mais no meio espúrio.

Não obstante, no caso dos autos não se está diante do denominado “pequeno traficante”, na medida em que, frise-se, localizada vultosa quantidade de drogas variadas, o que indica evidente ligação com organização criminosa, ou, ao menos, dedicação a atividades ilícitas bastante a lhe gerar a confiança necessária para que participasse ativamente daquela transação, onde há transporte de entorpecentes em volume alentado, a mando de terceiro.

Importante anotar que o fato de a vasta quantidade de entorpecentes ter sido considerada em primeira etapa da dosimetria para elevar a pena base, não prejudica a consideração desta mesma circunstância para que se entenda que o acusado dedica-se a atividades criminosas e integre organização criminosa, impedindo a aplicação do mencionado redutor.

Não há se falar em “bis in idem”, na medida em que não é a quantidade das drogas que está a impedir a aplicação do benefício, mas sim o fato de o réu dedicar-se a atividades espúrias, conclusão esta que se chega, aí sim, através do primeiro fato comprovado.

Neste sentido, manifesta-se uníssona a jurisprudência pátria: TRÁFICO. Quantidade expressiva. Apreensão de 537,49 gramas de cocaína com jovem de 19 anos e 4 meses de idade, e sete anotações na Vara da Inf. e Juventude, pese ainda criminalmente primário. Alguém que não estuda, não provou existência de economia suficiente para posse de tamanha quantidade de estupefacientes. Quadro de circunstâncias que conduzem à vinculação ao tráfico organizado. Provido o recurso ministerial para agravar a reprimenda, desprovido o defensivo, com base em farta e recentíssima jurisprudência do e. STJ. (...) Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas apreendidas (2,206 kg de cocaína), elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstra que aquele paciente se dedicava às atividades criminosas. Noutras palavras, embora a quantidade de entorpecentes apreendidos possa ser utilizada na primeira fase da dosimetria penal, para exasperar a reprimenda de piso, nada impede que tal circunstância seja novamente considerada na terceira etapa, para aferir a traficância habitual e, conseqüentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. E isso porque, “de acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há 'bis in idem' quando a quantidade da droga apreendida, apesar de utilizada na primeira etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-base, não foi usada para definir o patamar da fração redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como fator impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu meio de vida” (AgRg no REsp 1.580.686/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 01/02/2017). É o que ora fazemos. Certo é que “A col. Suprema Corte preocupou-se em evitar a dupla valoração

da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e na definição do patamar da fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (...) Na hipótese, a majoração da pena base está fundada na quantidade de drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem" (STJ, HC 483.227/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 19/03/2019).

A orientação foi repetida por ocasião do julgamento, ainda no e. STJ, do AgRg no HC 472.650/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26.2.2019: "(...) Hipótese em que a Corte de origem sopesou validamente a quantidade e a natureza da droga apreendida (1,05 kg de cocaína) na primeira etapa da dosimetria penal, para exasperar a pena-base em 6 meses de reclusão, e na terceira fase, para justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que tais vetores indicam a habitualidade delitiva da agravante".

Ora, é absolutamente inviável se entender que determinada pessoa foi presa na posse de cerca de setecentos e setenta porções de entorpecentes variados, e que esta mesma pessoa, por outro lado, não tem qualquer envolvimento com o crime organizado ou com atividades criminosas.

Máxime quando dono de maus antecedentes, inclusive em razão da prática do mesmo crime.

Desta forma, inaplicável o privilégio.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta.

Absolutamente incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, tendo em vista que aquela excede a quatro anos, bem como em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos acusados, consideradas em primeira etapa da dosimetria.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu DANILO MACÊDO DOS SANTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 700 (setecentos) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis, ainda, os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, de forma que mantenho a custódia do condenado, caso queira recorrer, mormente agora, o sentenciado tendo recebido duras penas, o que ressoa evidente que, caso em liberdade, não irá se colocar voluntariamente, no futuro, a seu cumprimento.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido a fls. 20 (R\$ 160,00) ao FUNAD, posto que evidente produto do tráfico de drogas, requisitando-se, para tanto, o encaminhamento do respectivo comprovante de recolhimento judicial junto à autoridade policial.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06